



Ir al portal SUIN-Juriscol



Ayúdanos a mejorar



Imprimir la norma



Responder Encuesta

Fecha Providencia	21/07/1998
-------------------	------------

Magistrado ponente: Fabio Morón Díaz

Norma demandada: Artículos 65 (parcial), 73 (parcial), 75 (parcial), 90, 91, 92, 93, 128, 147 (parcial), 155, 156, 162, 182, 187, 189 (parcial), 234, 240, 250, 267 (parcial), 279 (parcial), 307, 344 (parcial), 409 y 470, del Código Sustantivo del Trabajo.

Sentencia C-372/98

JORNADA LABORAL EN CARGOS DE DIRECCION, DE CONFIANZA Y DE MANEJO

Los cargos de dirección, de confianza y de manejo revisten una especial importancia en cualquier organización, resultando esenciales al cabal desarrollo de sus actividades, a la preservación de sus intereses fundamentales y a la realización concreta de sus fines. Por lo tanto, la consagración de estas actividades como una excepción a la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo se inscribe dentro de la facultad que asiste al legislador para

definir situaciones específicas en las que se justifique solicitarle al trabajador una disponibilidad diferente, toda vez que la responsabilidad aneja a actividades de esta índole es de mayor entidad que la originada en funciones corrientes.

JORNADA LABORAL PARA SERVICIO DOMESTICO-Tiempo máximo/HORAS EXTRAS PARA SERVICIO DOMESTICO-Tiempo máximo/HORAS EXTRAS PARA SERVICIO DOMESTICO

Una jornada laboral excesiva contradice los principios de la dignidad humana y las condiciones justas en que han de cumplirse las tareas domésticas, tornándose indispensable fijar un límite al período de trabajo que exceda de la jornada máxima ordinaria, límite por fuera del cual se quebrantarían las garantías mínimas del trabajador. Sólo en las anteriores condiciones la norma acusada puede ser exequible, de modo que aún cuando sea posible la exigencia de laborar durante un período de tiempo superior a la jornada máxima fijada legalmente, para la Corte lo razonable es que, en ningún caso, los trabajadores del servicio doméstico laboren más de 10 horas diarias, y en el evento de que se requiera el servicio más allá de tal límite, procederá entonces, el reconocimiento y pago de horas extras, en los términos de la legislación laboral.

PENSION SANCION-Carácter prestacional

La pensión sanción prevista para los empleados no afiliados al régimen de seguridad es de carácter prestacional, no pudiendo entenderse, por ende, como un castigo impuesto al empleador. Ello explica por qué el empleador tiene ante sí varias alternativas dispuestas por el ordenamiento y que, en líneas generales, consisten en continuar pagando las cotizaciones que falten para que el trabajador finalmente acceda a la pensión de vejez, no pagar esas cotizaciones respondiendo, entonces, por la cancelación de la pensión sanción durante la vida del trabajador o conmutar la pensión con el seguro social.

PENSION SANCION-Alcance y no extensión

No siendo idéntica la situación de unos trabajadores y otros, mal podría como se pretende en la demanda, que se otorgue el mismo trato a los empleados públicos regidos por relación legal y a los trabajadores oficiales vinculados por contrato de trabajo, pues ello equivaldría a eliminar la forma de vinculación, permanencia y retiro de los mismos, no obstante, que como se ha dicho, el legislador puede establecer distintas clases de regímenes respecto de los trabajadores del Estado.

Referencia: Expediente D-1923

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 65 (parcial), 73 (parcial), 75 (parcial), 90, 91, 92, 93, 128, 147 (parcial), 155, 156, 162, 182, 187, 189 (parcial), 234, 240, 250, 267 (parcial), 279 (parcial), 307, 344 (parcial), 409 y 470, del Código Sustantivo del Trabajo.

Actor: Luis Alvaro Rodríguez Beltrán

Magistrado Ponente:

Dr. FABIO MORON DIAZ.

Santafé de Bogotá, D.C., julio veintiuno (21) de mil novecientos noventa y ocho (1998)

I. ANTECEDENTES

El ciudadano **LUIS ALVARO RODRIGUEZ BELTRAN**, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, solicitó a esta Corporación la declaración de inexequibilidad de los artículos 65 (parcial), 73 (parcial), 75 (parcial), 90, 91, 92, 93, 128, 147 (parcial), modificado por el artículo 19 de la ley 50 de 1990; 155, 156, 162, 182, 187, 189 (parcial), modificado por el artículo 14 del decreto 2351 de 1965; 234, 240, 250, 267 (parcial), modificado por el artículo 133 de la ley 100 de 1993, 279 (parcial), modificado por el artículo 2º de la ley 71 de 1988; 307, 344 (parcial), 409 y 470, modificado por el artículo 37 del decreto 2351 de 1965; todos del Código Sustantivo del Trabajo.

Por auto de 12 de diciembre de 1997, el Magistrado Sustanciador decidió rechazar la demanda en relación con los artículos 65 numeral 1o.; 73 (parcial); 75 (parcial); 90; 91; 92; 93; 128 modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990; 155 modificado por el artículo 4 de la Ley 11 de 1984; 182; 187 parcial; 189 (parcial), modificado por el artículo 14 del decreto 2351 de 1965; 234; 240 (parcial); 250; 279 (parcial), modificado por el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 y los artículos 34, 40 y 69 de la Ley 100 de 1993; 307; 344 (parcial), 409 (parcial) y 470, todos del estatuto laboral colombiano, por existir cosa juzgada constitucional.

En la misma providencia se admitió la demanda contra los artículos 65 numeral 2; 147; 156; 162 (parcial) y 267, todos del cuerpo normativo laboral. Se ordenó, a su vez, fijar en lista el negocio, correr traslado del expediente al señor Procurador General de la Nación, para efectos de recibir el concepto de su competencia y enviar las comunicaciones respectivas al señor Presidente de la República, y al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Una vez cumplidos todos los trámites propios de esta clase de actuaciones procede la Corte a decidir:

II. EL TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS

Se transcriben a continuación las normas acusadas, subrayando los segmentos demandados:

“Artículo 65. INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO.

“1º Si a la terminación del contrato, el patrono no paga al trabajador salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo.

“2º Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el patrono cumple con sus obligaciones consignando ante el juez del trabajo y, en su defecto ante la primera autoridad política del lugar, la suma que confiese deber mientras la justicia del trabajo decide la controversia.

“3° En la misma sanción incurre el patrono cuando no haga practicar al trabajador el examen médico y no le expida el correspondiente certificado de salud de que trata el ordinal 7° del artículo 57.”

....

“Artículo 147. PROCEDIMIENTO DE FIJACION.

“1° El salario mínimo puede fijarse en pacto o convención colectiva o en fallo arbitral.

“2° El consejo nacional laboral, por consejo fijará salarios mínimos de carácter general, o para cualquier región o actividad profesional, industrial, comercial, ganadera, agrícola o forestal de una región determinada. En caso de que no haya consenso en el consejo nacional laboral, el gobierno, por medio de decretos que regirán por el término que en ellos se indique, puede fijar dichos salarios.

“3° Para quienes laboren jornadas inferiores a las máximas legales y devenguen el salario mínimo legal o el convencional, éste regirá en proporción al número de horas efectivamente trabajadas, con excepción de la jornada especial de treinta y seis horas prevista en el artículo siguiente.”

....

“Artículo 156.EXCEPCIÓN EN FAVOR DE COOPERATIVAS Y PENSIONES ALIMENTICIAS. *Todo salario puede ser embargado hasta en un cincuenta (50%) en favor de cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil”.*

“Artículo 162. EXCEPCIONES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES.

“1° Quedan excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo los siguientes trabajadores:

“a) Los que desempeñen cargos de dirección, de confianza o de manejo.

“b) Los del servicio doméstico, ya se trate de labores en los centros urbanos o en el campo.

“c) Los que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia, cuando residan en el lugar o sitio de trabajo”.

“Artículo 267. Reformado por el artículo 133 de la ley 100 de 1993. PENSION SANCION. *El artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 37 de la ley 50 de 1990, quedará así:*

“El trabajador no afiliado al sistema general de pensiones por omisión del empleador, que sin justa causa sea despedido después de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de (15) quince años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la presente Ley, tendrá derecho a que dicho empleador lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad si se es hombre, o cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.

“Si el retiro se produce por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión se pagará cuando el trabajador despedido cumpla cincuenta y cinco (55) años de edad si se es hombre o cincuenta (50) años de edad si se es mujer, o desde la fecha del despido si ya los hubiere cumplido.

“La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de la prima media con prestación definida y se liquidará con base en el promedio devengado en los últimos diez (10) años de servicios, actualizados con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor certificada por el DANE”.

“Parágrafo 1º. *Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará exclusivamente a los servidores públicos que tengan la calidad de trabajadores oficiales y a los trabajadores del sector privado.*

“Parágrafo 2º. *Las pensiones de que trata el presente artículo podrán ser conmutadas con el Instituto de Seguros Sociales.*

“Parágrafo 3º. *A partir del 1º de enero del año 2014 las edades a que se refiere el presente artículo se reajustarán a sesenta y dos (62) años si es hombre y a cincuenta y siete (57) años si es mujer, cuando el despido se produce después de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de quince (15) años, y a sesenta (60) años si es hombre y a cincuenta y cinco (55) años si es mujer, cuando el despido se produce después de quince (15) años de dichos servicios”*

III. LA DEMANDA

Los cargos de inconstitucionalidad pueden resumirse así:

- En cuanto al artículo 65, el actor considera que infringe los artículos 1, 29 y 229 de la Carta, toda vez que la retención contemplada en la normatividad cuestionada, hecha de manera directa por el empleador, constituye ejercicio arbitrario de la justicia por parte de los particulares, siendo que esta facultad no les es conferida por la Constitución. Según el actor, “toda persona debe tener derecho a acceder a la administración de justicia, y sólo a ésta le corresponde determinar qué es justo y qué no lo es”.

- Expresa el demandante que el artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 19 de la Ley 50 de 1990, desconoce el Preámbulo y los artículos 1, 2, 35, 38, 39, 53, y 55 del ordenamiento superior, pues soslaya el consenso como mecanismo para fijar las pautas salariales y atenta contra el fin de la búsqueda de la justicia social, siendo contradictorio que un Estado Social de Derecho, que considera al trabajo como derecho fundamental, acepte como viable el totalitarismo en materia laboral y especialmente en la asignación del salario mínimo.

- En lo que atañe al artículo 156 del estatuto del trabajo, el actor lo señala como violador de los artículos 42 y 55 superiores, porque, de acuerdo con su criterio, la Carta Política establece que corresponde al Estado la protección integral de la familia, y ese mandato se desconoce al consagrar la norma acusada una excepción, por virtud de la cual se permite que el salario pueda ser objeto de embargo en favor de las cooperativas, siendo que en últimas, éste es el único recurso con que cuenta el núcleo familiar. Agrega el libelista que no existe justificación alguna para que se privilegie a tales entidades frente al resto de acreedores, a quienes se discrimina en relación con la prerrogativa

que la disposición consagra para esas instituciones, por cuanto la economía solidaria en la actualidad ha dejado de desempeñar el papel que tuvo en el campo económico, constituyéndose en una actividad mercantil similar a la que realizan las demás entidades financieras.

- En cuanto a los literales acusados del artículo 162, indica el demandante que contienen disposiciones discriminatorias y desconocedoras del derecho a trabajar en condiciones dignas y justas, ya que si un empleador cuenta con trabajadores irreemplazables debe pagarles su especialidad, pues no es lógico que la capacitación obtenida se convierta a la postre "en algo contrario" a los intereses del trabajador, a quien de ese modo se le niega la igualdad de oportunidades respecto del resto de los empleados.
- Finalmente, sobre los segmentos acusados del artículo 267 del Estatuto Laboral, modificado por los artículos 37 de la Ley 50 de 1990 y 133 de la Ley 100 de 1993, señala el demandante que se oponen a los artículos 25, 46, 47 y 48 de la Carta, "como quiera que la pensión sanción no es un castigo al empleador por no haber afiliado al trabajador al sistema general de pensiones sino por el hecho de haberle impedido al trabajador cumplir con los requisitos para acceder a la pensión plena de jubilación" y, de otra parte, estima que el párrafo primero desconoce el artículo 13 superior, por cuanto discrimina a los empleados públicos frente a los trabajadores oficiales en cuanto a la llamada pensión sanción se refiere, pues si bien ambos tipos de vinculación son diferentes, esto no justifica que dicha prestación se limite a quienes tienen una vinculación contractual con el Estado, negándosela a quienes tienen una vinculación legal o reglamentaria.

Concluye el demandante manifestando que no obstante existir en materia laboral administrativa la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho, ésta "resulta en grado superlativo restringida, por lo que al conllevar la referida acción el reintegro, no procedería la pensión sanción, pero es evidente que esos reintegros no siempre se cumplen, por lo que a cambio de estos, o frente a la imposibilidad de haberlos, debería existir la alternativa de la pensión sanción, con el objeto de no vulnerar la norma acusada, el derecho al trabajo".

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

- El concepto fiscal empieza señalando que la Corte debe declararse inhibida para pronunciarse sobre los artículos 65-2, 162 literales a) y b); del Código Sustantivo del Trabajo, por considerar que el actor se limita a transcribirlos, sin realizar una exposición razonada de los motivos en que funda su petición, con lo cual se deja de cumplir uno de los requisitos materiales para la prosperidad de la acción.
- Respecto del artículo 147 del Estatuto Laboral, señala el ministerio público que la Corte debe declararse inhibida para fallar de fondo, ya que el precepto cuestionado, el cual fue subrogado por el artículo 19 de la Ley 50 de 1990, fue derogado por los artículos 1º, 2º y 8º de la Ley 278 de 1996.
- En lo atinente al artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo puntualiza el señor Procurador que "el salario de los trabajadores debe cumplir la finalidad económica y social a que está destinado" y que "la inembargabilidad del salario mínimo está íntimamente vinculada con la propia subsistencia del trabajador y la de su familia en condiciones dignas que involucran por lo tanto al mínimo vital, por ello se solicita a la Corte condicionar su constitucionalidad en el entendido que la prerrogativa establecida por la disposición acusada a favor de las cooperativas legalmente autorizadas para el embargo del 50% de 'todo' salario, sólo podrá aplicarse al excedente del salario mínimo legal o convencional".

Continúa señalando que "de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, y 13 de la Constitución Política, las cooperativas requieren de un tratamiento distinto al que se le da a las demás asociaciones con ánimo de lucro, toda vez que en su constitución, organización y finalidad son diferentes de aquellas, y además, porque son el producto de la actividad solidaria de los trabajadores en busca de una mejor calidad de vida, sirven a la comunidad y promueven la prosperidad general". Por tanto, dice el jefe del Ministerio Público, no hay atentado contra el derecho a la igualdad.

- Por último, expresa el Ministerio Público que es constitucional el párrafo cuestionado del artículo 267 del Código Laboral, ya que sobre el argumento del actor se pronunció la Corporación en la sentencia C-664 de 1996, al decidir una demanda presentada en contra del artículo 8º de la Ley 171 de 1961.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Primera. La Competencia

En virtud de lo establecido en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, por tratarse de disposiciones que forman parte de una ley de la República.

Segunda. La materia

1. Habiéndose rechazado la demanda en relación con los apartes cuestionados de los artículos 65-1, 73, 75, 90, 91, 92, 93, 128, 155, 182, 187, 189, 234, 240, 250, 279, 307, 344, 409 y 470, del Código Sustantivo del Trabajo, la Corte limitará su análisis a los segmentos de los artículos 65-2, 147, 156, 162 y 267, cuya inexequibilidad pretende el demandante.

2. Del artículo 65-2 del Código Sustantivo del Trabajo el actor solicita la inconstitucionalidad de la expresión "si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o", sin presentar en la demanda cargo alguno, por cuanto el concepto de violación esgrimido tiene que ver con el numeral 1º, respecto del cual se rechazó la demanda. En tales condiciones, lo que le corresponde a esta Corporación es declararse inhibida.

3. En cuanto tiene que ver con el artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo, relativo a la fijación del salario mínimo, demandado en la parte que reza "En caso de que no haya consenso en el consejo nacional laboral, el gobierno, por medio de decretos que regirán por el término que en ellos se indique puede fijar dichos salarios", debe recordarse que la Corte Constitucional puso de presente que "El Congreso Nacional, expidió, el 30 de abril de 1996, la ley 278 de 1996, en desarrollo del artículo 56 de la Constitución. Ley que determina la integración de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, sus funciones y otros aspectos relacionados con su funcionamiento. El artículo 8º de esta Ley subrogó el numeral 2º del artículo 147 acusado".[1] Por esta razón la Corte se declaró inhibida y tomará idéntica determinación en esta oportunidad.

4. Sobre el artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo que autoriza el embargo de hasta el 50% del salario "en favor de cooperativas legalmente autorizadas", la Corporación se pronunció en la sentencia C-589 de 1995, declarando la exequibilidad del segmento destacado, de modo que por haber operado el fenómeno procesal de la cosa juzgada constitucional, la Corte no procede a efectuar un nuevo examen y, en consecuencia, ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia citada.[2]

5. Del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, referente a las exclusiones de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo, el actor demanda los literales a) y b), relativos, en su orden, a los trabajadores que desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo y a los del servicio doméstico, ya se trate de labores en centros urbanos o en el campo.

La Corte no comparte el criterio del señor Procurador General de la Nación, quien le pide declararse inhibida para conocer de la constitucionalidad de los literales puestos en tela de juicio, aduciendo que el demandante no expuso el concepto de la violación, cuando lo cierto es que el actor presentó un cargo consistente en que la preceptiva demandada consagra una discriminación en contra de los trabajadores exceptuados y a la vez les desconoce el derecho a laborar en condiciones dignas y justas, ya que, a juicio del actor, el empleador debe pagarles su “especialidad” y si no lo hace quebranta el principio a trabajo igual salario igual, así como el derecho a la igualdad de oportunidades, “respecto a los demás trabajadores”.

Esta Corte ha estimado que “la protección al trabajo establecida por mandato del artículo 25 constitucional, incluye la fijación de jornadas máximas, dentro de las cuales los trabajadores presten los servicios propios de la relación laboral y estén sometidos a las órdenes del patrono”, [3] situación que se acompasa con el necesario descanso que es un derecho y que tiene como fines, entre otros, permitirle al trabajador “recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud física y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que permitan su desarrollo integral como persona”. [4]

Lo anterior, sin embargo, no obsta para que atendida la especial naturaleza de las actividades que determinados trabajadores cumplen al servicio de un empleador y sin perjuicio del derecho al descanso, se prevea una mayor disponibilidad que la exigida a los demás operarios. Tal posibilidad es desde todo punto de vista excepcional y, según la jurisprudencia de esta Corporación, las hipótesis en las que haya lugar a demandar la presencia del trabajador en días y horas distintos a los de la jornada normal no deben quedar al capricho del empleador, sino que han de venir previamente definidas en la ley y obedecer a circunstancias objetivas y razonables.

En este orden de ideas, cabe precisar que los cargos de dirección, de confianza y de manejo revisten de una especial importancia en cualquier organización, resultando esenciales al cabal desarrollo de sus actividades, a la preservación de sus intereses fundamentales y a la realización concreta de sus fines. Por lo tanto, la consagración de estas actividades como una excepción a la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo se inscribe dentro de la facultad que asiste al legislador para definir situaciones específicas en las que se justifique solicitarle al trabajador una disponibilidad diferente, toda vez que la responsabilidad aneja a actividades de esta índole es de mayor entidad que la originada en funciones corrientes.

Acerca de este tópico, vale la pena transcribir las consideraciones de la H. Corte Suprema de Justicia que, aún cuando fueron hechas antes de la Constitución de 1991, a juicio de esta Corporación, son plenamente ajustadas al nuevo orden superior:

“Se observa en primer lugar que, por razón de los caracteres particulares de algunos trabajos o actividades, el legislador se vio obligado a crear una especial categoría de trabajadores que, para ciertos efectos, sometió a un régimen especial, como ocurre en lo referente a la jornada máxima de trabajo y al fuero sindical.

“Por lo que hace al punto que interesa al caso en estudio, el artículo 162 del Código sustantivo del Trabajo, estableció lo siguiente: ‘Quedan excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo los siguientes trabajadores: a) Los que desempeñen cargos de dirección, de confianza o de manejo;...’. Esos términos ‘de dirección, de confianza o de manejo’ que utiliza la ley, no implican categorías distintas conforme al significado

gramatical de las palabras que emplea, sino que abarcan una institución única, traducen una sola idea y son la expresión legal del concepto 'trabajadores de confianza', nacido de las necesidades y del interés de las empresas. Por otra parte, se trata de un concepto genérico, que no es susceptible de numeración limitativa, y que, por consiguiente para precisar si una determinada actividad implica el desempeño de un cargo 'de dirección, de confianza o de manejo' debe estudiarse en cada caso la respectiva relación de trabajo, en función de los intereses y necesidades fundamentales de cada empresa, cuestión que corresponde al juzgador pues el derecho del trabajo no abandona a la voluntad de los particulares la fijación de sus conceptos.

"En apoyo de lo anterior, es oportuno citar lo expresado sobre el particular por el tratadista Mario de la Cueva en su obra Derecho Mexicano del Trabajo, que dice: 'Ahí donde están en juego la existencia de la empresa, sus intereses fundamentales, su éxito, su prosperidad, la seguridad de sus establecimientos, el orden esencial que debe reinar entre sus trabajadores, debe hablarse de empleados de confianza'.

"No basta, pues, para incluir dentro del régimen exceptivo que consagra el artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, a las personas que ocupan ciertos y determinados puestos, porque estos sean de confianza, sino que es indispensable que la función que se desempeñe en los puestos de que se trata sea **sustancialmente de confianza** y este carácter depende de las actividades que se desempeñen. Así lo ha entendido la jurisprudencia al expresar: 'Desde luego, en todo trabajador, se deposita un mínimo de confianza que responde a las exigencias de lealtad, honradez, aptitud y demás calidades derivadas de la especial naturaleza de la relación laboral. Pero cuando a esas condiciones comunes se agregan otras que por comprometer esencialmente los intereses morales o materiales del patrono, implican el ejercicio de funciones propias de éste, el elemento confianza adquiere singular relieve y por ello se le usa para calificar o distinguir el carácter del empleado' (Casación 7 de noviembre de 1950, Gaceta del Trabajo, Tomo V, Pág. 900).

"Además, el concepto que implica el término -cargo de confianza-, según el alcance y contenido que se deja expuesto, no ha de existir solamente en un momento de la relación de trabajo, pues no puede calificarse como empleado de confianza a aquél que, no siéndolo según sus funciones esenciales y permanentes, en un momento dado y con carácter transitorio, para llenar vacíos en la empresa le sean asignados o impuestos servicios de tal, por el patrono.

"En efecto, si esta especial categoría de trabajadores, creada por el legislador, obedece de manera esencial o fundamental a la necesidad de las empresas de proteger sus altos intereses, su propiedad o patrimonio, parece lógico deducir que las personas señaladas o escogidas por el patrono para realizar esas determinadas actividades o funciones, lo sean en atención a sus antecedentes personales, a su capacidad y moralidad, además de los conocimientos técnicos que el cargo requiera; esto hace suponer que debe tratarse de situaciones estables a las que de ordinario llega el trabajador bien sea por sus antecedentes y trayectoria en la prestación de servicios anteriores a la empresa, o porque sus calidades especiales de que es poseedor y de que seguramente tiene conocimiento el empleador, le permiten obtener esa clase de distinciones para desempeñar un cargo de dirección, de confianza o de manejo".[5]

Son suficientes las anteriores consideraciones para desestimar el cargo formulado.

De otra parte, en relación con el literal b) del artículo 261, referente a la excepción al régimen de jornada máxima para los trabajadores del servicio doméstico, la Corporación considera que el legislador sustrajo de dicho régimen la labor doméstica teniendo en cuenta que la familia no tiene las características de una empresa o de un patrono corriente o regular, pues es evidente que la economía doméstica y la labor desempeñada en la misma poseen unos rasgos particulares que implican una disponibilidad de tiempo diferente y adecuada a las actividades familiares, que no son asimilables a las desplegadas en otros ámbitos del quehacer económico o social.

Ya esta Corte estimó que “por las características propias de esta modalidad de trabajo” es “razonable la disposición del literal b) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, que excluye de la regulación sobre jornada máxima legal a los trabajadores del servicio doméstico”. [6]

Empero, si bien es cierto que la familia tiene características singulares que no la asimilan a un patrono corriente, la Corte estima pertinente conciliar la protección que la Constitución brinda al núcleo familiar con las condiciones dignas y justas en que, de conformidad con la misma Carta Política, debe desarrollarse la actividad doméstica.

A este propósito es menester diferenciar dentro de la actividad doméstica la situación de los servidores que habitan en la casa del patrono y allí toman sus alimentos, de la situación de aquellas personas que cumplen estas labores en condiciones distintas a las que se dejan expuestas, por cuanto la preceptiva demandada tiene por supuesto la primera de las hipótesis descritas.

En este orden de ideas, a juicio de la Corte, una jornada laboral excesiva contradice los principios de la dignidad humana y las condiciones justas en que han de cumplirse las tareas domésticas, tornándose indispensable fijar un límite al período de trabajo que exceda de la jornada máxima ordinaria, límite por fuera del cual se quebrantarían las garantías mínimas del trabajador.

Sólo en las anteriores condiciones la norma acusada puede ser exequible, de modo que aún cuando sea posible la exigencia de laborar durante un período de tiempo superior a la jornada máxima fijada legalmente, para la Corte lo razonable es que, en ningún caso, los trabajadores del servicio doméstico laboren más de 10 horas diarias, y en el evento de que se requiera el servicio más allá de tal límite, procederá entonces, el reconocimiento y pago de horas extras, en los términos de la legislación laboral.

La Corporación estima que la exequibilidad del literal b) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo objeto de cuestionamiento, condicionada en los términos establecidos, es la alternativa más razonable, ya que si llegara a declararse la inexequibilidad, bajo estrictas condiciones de solidaridad y dignidad del trabajador, no hay duda acerca de que ello tendría un efecto perverso, generando desempleo y, eventualmente, la desaparición del trabajo doméstico.

En lo que toca con los trabajadores del servicio doméstico que no viven con el patrono en forma permanente, la Corte estima que para ellos rigen las normas ordinarias en materia de garantías salariales y prestaciones sociales.

Finalmente, es de interés poner de manifiesto que esa mayor disponibilidad, exigible en los términos de los literales a) y b) del artículo 162 del Estatuto Laboral, no acarrea ni puede acarrear la renuncia al descanso compensatorio, aspecto sobre el cual ya se ha manifestado la Corporación, en términos que conviene reiterar ahora:

"En razón a la naturaleza de ciertas actividades, se hace necesario que algunos trabajadores laboren en los días de descanso obligatorio. En esos casos, que están expresamente consagrados por la ley (artículo 175), se ha previsto el derecho del trabajador a tomar un **descanso compensatorio**, que, en los términos del artículo 183 del mismo Código, consiste en que el descanso pueda tomarse en otro día laborable de la semana o, desde el medio día del domingo a las trece horas (1 p.m.), hasta el medio día o las trece horas (1 p.m.) del lunes.

Una de las excepciones consagradas por el artículo 175, hace referencia a aquellas labores que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o **por motivos de carácter técnico**. Norma que si bien establece el

deber del trabajador de laborar en días de descanso obligatorio, consagra el derecho correlativo a un **descanso compensatorio**.

La norma demandada parte del supuesto de que el trabajador no tiene derecho a su **descanso compensatorio**, cuando, por sus conocimientos técnicos o por la naturaleza de su trabajo, el empleador no podría reemplazarlo, porque ello implicaría un grave perjuicio para la empresa.

Si, como se ha explicado, el descanso obligatorio a que tiene derecho todo trabajador, busca otorgar protección a la salud de éste y permitirle la ejecución de otras actividades que le proporcionen un desarrollo integral de su ser, fines éstos que priman sobre intereses netamente económicos, no es constitucional una norma que, como la acusada, quebrante el derecho que tiene todo trabajador a cesar en su actividad, por determinado lapso.

La mayor remuneración que recibe el trabajador por laborar en días establecidos como de descanso obligatorio, no suple los fines que el descanso cumple.

Por lo expuesto, se declarará inexecutable la frase "sin derecho al descanso compensatorio" del artículo 182."[7]

6. Bajo el entendimiento de que la pensión sanción "no es un castigo al empleador por no haber afiliado al trabajador al sistema general de pensiones", sino por el hecho de haberle impedido "cumplir con los requisitos para acceder a la pensión plena de jubilación", el actor pide la inexecutable de la expresión "...no afiliado al sistema general de pensiones por omisión del empleador...", contenida en el primer inciso del artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por los artículos 37 de la ley 50 de 1990 y 133 de la ley 100 de 1993, pues en su criterio el reconocimiento de la pensión sanción no puede estar condicionado a la no afiliación del trabajador al sistema pensional.

Cabe aclarar que el inciso del que hace parte el segmento acusado fue declarado constitucional por esta Corporación, mediante sentencia No. C-410 de 1994, "pero únicamente en lo relativo al cargo formulado", [8] que en esa oportunidad lo fue el presunto quebrantamiento del principio de igualdad derivado de la consagración de una edad diferente para acceder a la pensión, dependiendo del sexo del trabajador. Como quiera que la acusación planteada en la presente causa es diferente, procede la Corte a emitir pronunciamiento de fondo.

Acerca de la pensión sanción, conviene recordar que su establecimiento se produjo por virtud del artículo 8º de la ley 171 de 1961 en favor del trabajador despedido sin justa causa "de una empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos (\$800.000.00), después de haber laborado para la misma o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos", y siempre que al momento del despido tuviera 60 años cumplidos, teniendo también lugar el reconocimiento desde la fecha en que cumpliera esa edad con posterioridad al despido o a los 50 años si el despido injustificado acontecía "después de quince (15) años de dichos servicios...".

El propósito subyacente a la previsión que se viene comentando, en palabras de la H. Corte Suprema de Justicia, no era otro que el de "disuadir a los empleadores que desearan despedir sin justa causa a trabajadores con antigüedad de servicio superior a los 10 años -y que no alcanzaran los 20-, asegurándoles una pensión proporcional que reemplazara en parte la jubilación plena frustrada por el despido abusivo", [9] finalidad perfectamente explicable si se tiene en cuenta que, dada la gradualidad de la cobertura, al momento de expedirse la ley 171 de 1961 el Seguro Social no había comenzado a asumir el riesgo de vejez y en tales condiciones la desprotección del trabajador despedido sin justa causa era más que evidente.

Así las cosas, la pensión sanción en su concepción inicial tuvo un marcado carácter indemnizatorio y equivalía a una pena impuesta al patrono y pese a que con posterioridad el Seguro Social asumió el riesgo de vejez, la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estimó que la pensión sanción y la de vejez eran concurrentes, interpretación que fue variando hasta admitir el carácter prestacional de la pensión sanción, reconociéndole así la misma naturaleza de la pensión de vejez y definiendo con claridad que los dos derechos no eran concurrentes.

Sobre el particular la H. Corte Suprema de Justicia ha considerado:

“Es innegable que hasta la expedición de la ley 50 de 1990 ningún precepto con fuerza de ley derogó de manera expresa la pensión por despido consagrada en la ley 171 de 1961, toda vez que los que hicieron alguna referencia a ella fueron reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, aprobados mediante decretos por el gobierno nacional, muchas veces imprecisos, y por su carácter subalterno carecían del poder de desquiciar totalmente la normatividad legal mencionada.

“Por las razones expuestas la jurisprudencia nacional paulatinamente fue esclareciendo las diversas consecuencias de los reglamentos citados procurando cada vez más armonizarlos con el marco legal subsistente, pero alejándose de las posturas extremas que en su momento propiciaron la compatibilidad entre la pensión sanción y la de vejez del I.S.S. o la extinción de este beneficio.

“Fue así como de la tesis sobre concurrencia de estos derechos preconizadas inicialmente en sentencias de la sección primera de la Sala Laboral de esta Corporación de noviembre 5 de 1976 y de noviembre 8 de 1979, prohijadas por la de la Sala Plena Laboral de mayo 22 de 1981, se pasó, el 13 de agosto de 1986, ya en vigencia del decreto 2879 de 1985, a deducir la exclusión de los dos beneficios para aquellos trabajadores que en el momento de iniciarse la obligación de aseguramiento por vejez tenían menos de 10 años de servicios al empleador, hasta que con base en el decreto 758 de 1990 se admitió la compatibilidad”. [10]

Del proceso al que sucintamente se ha aludido interesa destacar el cambio de la naturaleza sancionadora de la pensión comentada a una naturaleza prestacional, más acorde con los postulados que guían las modernas concepciones de la seguridad social. De esa evolución jurisprudencial y de la necesidad de poner la legislación a tono con los principios orientadores del derecho a la seguridad social, fueron conscientes el Gobierno Nacional y el Congreso de la República al impulsar la expedición de la ley 50 de 1990, cuyo artículo 37 subrogó el artículo 8º de la ley 171 de 1961.

En efecto, el Gobierno Nacional, en la exposición de motivos del pertinente proyecto de ley señaló:

“...La acción de reintegro, así como la llamada pensión sanción, tuvieron justificación cuando las pensiones de jubilación estaban a cargo del empleador y podía presumirse interés de éste en propiciar el despido, con el único fin de eludir la pensión. Hoy, cuando el Seguro Social ha asumido el riesgo de vejez, con base en el número correspondiente de cotizaciones, esta presunción carece de sentido, pues aún suponiendo una gran rotación, el trabajador conserva todos sus derechos frente al ISS y nada tiene que temer acerca de su pensión...”. [11]

En consonancia con los anteriores asertos, en la ponencia para el primer debate se indicó:

“Se elimina la pensión sanción respecto de los trabajadores amparados por el sistema de seguridad social a cargo del Instituto de Seguros Sociales. Se mantiene en su concepto original cuando dicha circunstancia no se presente. Esto es, el trabajador afectado por el despido será beneficiario de la pensión sanción a cargo del empleador si no ha cotizado para la pensión de vejez del ISS. Se prevé también la posibilidad de que se pueda completar la cotización a efectos de la proporcional de vejez cuando el trabajador no tenga el número mínimo de semanas y haya estado al servicio del empleador más de 10 o 15 años, así como la facultad que tendrá el empleador para conmutar las pensiones con el ISS”. [12]

Así pues, la implementación de un sistema de seguridad social que, dentro del principio de universalidad, aspira a amparar a un número creciente de personas frente a una mayor cantidad de riesgos, ejerce una notable influencia en figuras concebidas con el propósito de procurarle protección al trabajador, ya que, en la medida en que la cobertura del sistema se va ampliando, tales figuras tienden a desaparecer o cuando menos deben ser apreciadas bajo una concepción basada en fundamentos filosóficos distintos.

Eso es lo que ha acontecido con la pensión sanción, cuyo propósito protector encontraba justificación plena durante las épocas en las cuales el patrono asumía todos los riesgos, aún el de vejez y que, paralelamente a la variación de su naturaleza sancionadora, asistió a un proceso al cabo del cual su ámbito de protección decreció ante el avance paulatino del sistema de seguridad social que vino a cobijar el riesgo de vejez, antaño asumido exclusivamente por el empleador.

Tal es la razón por la que el legislador, actuando conforme a sus competencias, optó por extinguir la pensión sanción en la hipótesis de que el trabajador tenga el derecho a reclamar del sistema de seguridad social el reconocimiento de su pensión de vejez, pues en tales casos el patrono es sustituido en esa obligación, mientras que previó el mantenimiento de esa prestación a cargo del empleador que hubiere omitido afiliarse al sistema general de pensiones a su trabajador.

Es de interés insistir en que la pensión sanción prevista para los empleados no afiliados al régimen de seguridad es de carácter prestacional, no pudiendo entenderse, por ende, como un castigo impuesto al empleador. Ello explica por qué el empleador tiene ante sí varias alternativas dispuestas por el ordenamiento y que, en líneas generales, consisten en continuar pagando las cotizaciones que falten para que el trabajador finalmente acceda a la pensión de vejez, no pagar esas cotizaciones respondiendo, entonces, por la cancelación de la pensión sanción durante la vida del trabajador o conmutar la pensión con el seguro social.

A todas las cuestiones que se dejan consignadas se ha referido la H. Corte Suprema de Justicia, a propósito de la ley 50 de 1990 y en el entendimiento de que los criterios así expuestos “no han sufrido variación por virtud de lo dispuesto en la ley 100 de 1993”, cuyo artículo 133 subrogó el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo. Sobre el particular la Corte Suprema ha dicho:

“A partir de la vigencia del artículo 37 de la Ley 50 de 1990 -enero primero de 1991- la conceptualización legal de la pensión sanción sufrió un viraje fundamental pues teniendo en cuenta el nuevo tratamiento al despido injustificado, la aspiración de universalización de la seguridad social, el monto de la pensión de vejez consagrado desde 1985 y en general la inspiración filosófica de dicha normatividad, se puso de manifiesto que los fundamentos filosóficos que antaño justificaron tal figura sufrieron notoria mengua, de forma que ahora, no solamente aparece innecesaria sino que riñe con los postulados de una auténtica seguridad social, en la medida en que los empresarios cumplan sus deberes en esa materia, y así lo estatuyó la nueva preceptiva.

“Del artículo 37 de la Ley 50 surge con claridad que los despidos efectuados (después del primero de enero de 1991), por un empleador que a través de la relación laboral cumplió con sus obligaciones de afiliación oportuna y cotizaciones al sistema de seguridad social, debidamente acreditadas en juicio, no quedan afectados con la posibilidad de la pensión sanción, la que quedó extinguida en sus dos modalidades; corolario de ello es que se mantiene para los trabajadores no afiliados al régimen de seguridad social pertinente.

“Naturalmente, afiliaciones al ente de seguridad social efectuadas por empleadores con notoria extemporaneidad, y que ocasionen la privación de la pensión de vejez por parte de aquel constituyen un menoscabo de los derechos del trabajador despedido injustamente, y por ello no liberan al patrono de la obligación pensional, como ya ha tenido oportunidad de precisarlo esta Sala mediante sentencia del 29 de septiembre de 1994 (Exp. 6919), en la que expresó: ‘Como el principio general es que las pensiones restringidas deben dejar de estar a cargo de los empleadores cuando la pensión de vejez sea asumida por el Seguros Social (inciso cuarto), si se aceptara la tesis del recurrente -que desconoce ese principio- se llegaría a situaciones de desprotección no queridas por el legislador. Así por ejemplo, la del empleador que afiliara al trabajador tardíamente, inclusive el día anterior al despido, y pretendiera acogerse a lo dispuesto en el primer inciso del artículo 37 (en el entendimiento que le da e recurrente) para no pagar la pensión proporciona’.

“Igualmente para la hipótesis de cotizaciones deficientes, el parágrafo primero ibídem contempla la posibilidad de que el empleador continúe pagando el valor de las que falten para que el afiliado adquiera el derecho a la pensión de vejez; mas como se advirtió en la sentencia referida se trata de una facultad que puede ser renunciada por el empleador que a su elección prefiera abstenerse de continuar pagando el valor de esas cotizaciones y asumir él directamente el pago de la pensión restringida durante toda la vida del trabajador. Así mismo se observó que el parágrafo segundo del precepto, le permite al empleador convenir con el Seguro Social la conmutación de la pensión, hipótesis en la cual también se puede liberar de la obligación de continuar cotizando para ese riesgo.

“Conviene precisar que en los eventos de cotizaciones extemporáneas de los empleadores, permitidas por el ordenamiento positivo, constituye una obligación correlativa del ente gestor de la seguridad social respectivo el recibirlas, sin perjuicio del cobro de los intereses y demás consecuencias consagradas en la normatividad aplicable. Así se asegura el indispensable acoplamiento entre las normas laborales y las de seguridad social”. [13]

Siendo así las cosas, la Corte no observa las violaciones de los artículos 25, 46, 47 y 48 de la Constitución Política, que el actor endilga a la preceptiva acusada que, en consecuencia, será declarada exequible.

7. Cuestiona también el actor la constitucionalidad de algunos segmentos del parágrafo primero del artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, alegando que desconocen el derecho a la igualdad de los empleados públicos, quienes, en su opinión, resultan discriminados por estar excluidos del beneficio de recibir la pensión sanción en caso de ser despedidos sin justa causa.

Para declarar la exequibilidad de los apartes demandados, basta remitirse a las consideraciones hechas por la Corte Constitucional en la sentencia No. C-664 de 1996:

“Empero, dado que la misma norma cuestionada versa sobre la consecuencia que se genera con ocasión del despido de un trabajador vinculado por contrato de trabajo, sin tener en cuenta la situación de afiliación o no al Seguro Social, resulta procedente el examen de fondo de la cuestión planteada, toda vez que el demandante pretende que dicha disposición se haga extensiva igualmente a todos los servidores públicos frente a la circunstancia del retiro ilegal o sin justa causa y sin que se tenga en cuenta su vinculación contractual o legal o

reglamentaria con la administración pública en todos los niveles, lo cual amerita el análisis material de constitucionalidad.

“Nuestra Carta Política de 1991 estableció en forma meridiana que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

“Consecuente con lo anterior, es permisible que en la administración pública, determinados trabajadores se vinculan a ella a través de una relación legal o reglamentaria o en virtud de un contrato de trabajo, en la misma forma, para este último caso, que los trabajadores particulares.

“Los servidores públicos vinculados a través de la relación legal por el sistema de mérito o considerados de libre nombramiento y remoción de acuerdo con la ley, tienen un régimen laboral totalmente diferente al que existe para los trabajadores oficiales vinculados por una situación contractual, y por consiguiente todo lo relacionado con el sistema de ingresos, permanencia, retiro y régimen prestacional no es el mismo. Ya se ha dicho por esta Corporación cómo el principio de igualdad de que trata el artículo 13 de la Carta Política, no puede aplicarse sino a situaciones idénticas (sentencia No. C-410 de 1994, MP. Dr. Carlos Gaviria Díaz).

“En el presente asunto no siendo idéntica la situación de unos trabajadores y otros, mal podría como se pretende en la demanda, que se otorgue el mismo trato a los empleados públicos regidos por relación legal y a los trabajadores oficiales vinculados por contrato de trabajo, pues ello equivaldría a eliminar la forma de vinculación, permanencia y retiro de los mismos, no obstante, que como se ha dicho, el legislador puede establecer distintas clases de regímenes respecto de los trabajadores del Estado. Por consiguiente, el cargo no está llamado a prosperar.

“No obstante lo expresado, adicionalmente cabe advertir que tampoco resultan acertadas las apreciaciones que se hacen en la demanda, en el sentido de que la supresión de cargos y la remoción de los empleados de carrera afecta derechos de los servidores del Estado para los efectos del reconocimiento del tiempo servido, toda vez que en el evento de que estos sean retirados con violación de las normas superiores de derecho, pueden obtener a través de la acción laboral correspondiente que el tiempo durante el cual estuvieron cesantes a causa de la desvinculación ilegal se tenga en cuenta para los efectos prestacionales como la pensión de jubilación, la cesantía y los demás derechos inherentes de carácter laboral”. [14]

VI. DECISION

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Primero. Declarar **EXEQUIBLES** los literales a) y b) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, y, en el caso del literal b) la exequibilidad se condiciona en el sentido de que los trabajadores domésticos que residen en la casa

del patrono, no podrán tener una jornada superior a 10 horas diarias.

Segundo. Declarar **EXEQUIBLES** la frase “no afiliado al sistema general de pensiones por omisión del empleador”, contenida en el inciso primero del artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 133 de la ley 100 de 1993, y las expresiones “exclusivamente” y “que tengan la calidad de trabajadores oficiales” de su parágrafo primero.

Tercero. Declarar la **INHIBICION** de la Corte Constitucional para conocer sobre la constitucionalidad del segmento demandado del numeral 2º del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por falta de cargos en su contra y del aparte demandado del numeral 2º del artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo, por haber sido derogado por el artículo 8º de la ley 278 de 1996.

Cuarto. **ESTESE A LO RESUELTO** en la Sentencia No. C-589 de 1995, en relación con los apartes acusados del artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo.

Afectaciones realizadas: [\[Mostrar\]](#)

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

VLADIMIRO NARANJO MESA

Presidente

ALFREDO BELTRAN SIERRA

Magistrado

ANTONIO BARRERA CARBONELL

Magistrado

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

Magistrado

CARLOS GAVIRIA DIAZ

Magistrado

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Magistrado

HERNANDO HERRERA VERGARA

Magistrado

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

Magistrado

FABIO MORON DIAZ

Magistrado

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

Salvamento de voto a la Sentencia C-372/98

JORNADA LABORAL PARA SERVICIO DOMESTICO (Salvamento de voto)

Pienso que una norma legal a cuyo tenor todo un sector de trabajadores, sin justificación alguna, está excluido de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo, lo cual implica que estará expuesto de manera "lícita" a que se le exija laborar en forma continua durante veinticuatro horas al día, es abiertamente inconstitucional. Y esta Corte ha debido declararlo así de manera clara y contundente, retirando del sistema jurídico el literal b) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo. La Sentencia es contradictoria: declara la exequibilidad del precepto que excluye al aludido sector de trabajadores de la jornada máxima laboral, pero a renglón seguido la condiciona "en el sentido de que los trabajadores domésticos que residan en la casa del patrono no podrán tener una jornada superior a 10 horas diarias". En el fondo, aunque no lo dijera, la mayoría declaró la inexequibilidad de la norma acusada. Estoy de acuerdo, pero creo que ha debido hacerlo de manera explícita y sin incurrir en la inexplicable paradoja que señalo, lo cual muy posiblemente, al generar inseguridad jurídica, hará que en la práctica resulten inútiles las buenas intenciones de la Corte.

Referencia: Expediente D-1923

Por supuesto, en lo referente a la jornada laboral del servicio doméstico, estoy de acuerdo con la filosofía que inspira la Sentencia: la Constitución Política reconoce expresamente la dignidad de la persona humana (arts. 1 y 5); proclama la igualdad y proscribte toda clase de discriminaciones (art. 13 C.P.); prohíbe toda forma de esclavitud o de servidumbre (art. 17 C.P.); establece la garantía de protección especial para todas las modalidades del trabajo (art. 25 C.P.); consagra como derecho fundamental el trabajo en condiciones dignas y justas (art. 25 C.P.); estipula como fundamento básico del ordenamiento en materia laboral y como derecho mínimo de los trabajadores el que tienen al descanso necesario (art. 53 C.P.); y declara sin rodeos que "la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores" (art. 53 C.P.).

Pero precisamente por eso, pienso que una norma legal a cuyo tenor todo un sector de trabajadores, sin justificación alguna, está excluido de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo, lo cual implica que estará expuesto de manera "lícita" a que se le exija laborar en forma continua durante veinticuatro horas al día, es abiertamente inconstitucional. Y esta Corte ha debido declararlo así de manera clara y contundente, retirando del sistema jurídico el literal b) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo.

No lo hizo así la Corporación y declaró la exequibilidad del precepto. Ello significa que éste se aviene a la Constitución Política, y que es de esa premisa objetiva de la que se deriva la conclusión, con fuerza de verdad jurídica, según la cual es exequible -ejecutable-. A esta consecuencia arriba el Juez de constitucionalidad sólo cuando no encuentra oposición entre una norma de la ley y la Constitución.

Por tanto, el contenido esencial del literal examinado -que los trabajadores del servicio doméstico estén excluidos de la jornada laboral máxima- no fue hallado incompatible con los mandatos del Estatuto supremo dentro de la estructura jurídica del Estado. Únicamente por esa razón merece permanecer dentro del ordenamiento. De lo contrario, ha debido ser inmediatamente retirado de él.

La Corte, a pesar de reconocer, como lo hace en la parte motiva del Fallo, que es "indispensable fijar un límite al período de trabajo que exceda de la jornada máxima ordinaria, límite por fuera del cual se quebrantarían las garantías mínimas del trabajador" (subrayado mío), expresa que el precepto "puede ser exequible" y así lo declara.

La exequibilidad en este caso se debe, según la Sentencia, a una consideración que, en mi criterio, es de pura conveniencia y, por ende, ajena a la función de defensa de la Carta que a esta Corporación corresponde: "...si

llegara a declararse la inexequibilidad, bajo estrictas condiciones de solidaridad y dignidad del trabajador, no hay duda acerca de que ello tendría un efecto perverso, generando desempleo y, eventualmente, la desaparición del trabajo doméstico".

Además de la falta de argumentos para sostener ese peculiar fundamento de la exequibilidad, me parece preocupante que la Corte no busque realizar el principio constitucional de la solidaridad ni la dignidad del trabajador "bajo estrictas condiciones". Debería hacerlo así: no olvidemos que el trabajo, la solidaridad de las personas que integran el conglomerado sujeto al orden jurídico y la dignidad de la persona humana son fundamentos del Estado Social de Derecho y del sistema que la Constitución instaure, como con claridad lo proclama su artículo primero.

Ahora bien, desde el punto de vista lógico, la Sentencia es contradictoria: declara la exequibilidad del precepto que excluye al aludido sector de trabajadores de la jornada máxima laboral, pero a renglón seguido la condiciona "en el sentido de que los trabajadores domésticos que residan en la casa del patrono no podrán tener una jornada superior a 10 horas diarias".

En el fondo, aunque no lo dijera, la mayoría declaró la inexequibilidad de la norma acusada. Estoy de acuerdo, pero creo que ha debido hacerlo de manera explícita y sin incurrir en la inexplicable paradoja que señalo, lo cual muy posiblemente, al generar inseguridad jurídica, hará que en la práctica resulten inútiles las buenas intenciones de la Corte.

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Magistrado

Fecha, ut supra.

[1] Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-710 de 1996. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.

[2] Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-589 de 1995. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.

[3] Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-024 de 1998. M. P. Dr. Hernando Herrera Vergara.

[4] Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-710 de 1996. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.

[5] Cf. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia de julio 23 de 1959. M.P. Dr. Luis Fernando Paredes A.

[6] Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia NO. C-051 de 1995. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.

[7] Cf. Corte Constitucional Sala Plena. Sentencia NO. C-710 de 1996 M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.

[8] Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-410 de 1994. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.

[9] Cf. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sección segunda. Sentencia de septiembre 29 de 1994. M.P. Dr. Hugo Suescún Pujols.

[10] Cf. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sección Segunda. Sentencia de agosto 22 de 1995. M.P. Dr. José Roberto Herrera Vergara.

[11] Cf. Anales del Congreso, martes 2 de octubre de 1990, página 8.

[12] Cf. Anales del Congreso, miércoles 7 de noviembre de 1990, página 8.

[13] Cf. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sección Segunda. Sentencia de agosto 22 de 1995. M.P. Dr. José Roberto Herrera Vergara.

[14] Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-664 de 1996. M. P. Dr. Hernando Herrera Vergara.